

1503197-30.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... da abordagem, os antecedentes específicos no tráfico (reincidente específico) e o depoimento incriminador dos agentes públicos, tudo a apontar o réu como pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503197-30.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503197-30.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2273491/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 27894532 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2273491 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN DOS SANTOS GIMENES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

JONATHAN DOS SANTOS GIMENES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de outubro de 2022, por volta das 09h40min, na Rodovia Rotatória Via Antonio Cruanes Filho, nº 3000, Jardim Santa Cecília, na cidade e comarca de Limeira, o acusado trazia drogas consigo, para venda ou entrega a terceiros, tratando-se de um tubo plástico com 50 (cinquenta) pedras de crack contendo 5,67 gramas, e R\$51,10 reais em dinheiro, sendo certo que agia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão, fotografias e laudo químico-toxicológico definitivo.

Segundo se apurou, guardas civis municipais, em apoio aos funcionários do CEPROSOM que faziam cadastro de moradores de rua, avistaram o denunciado em um barraco, jogando algo para trás do sofá. Neste momento, os agentes públicos foram averiguar o que foi jogado, quando então encontraram 50 (cinquenta) pedras de crack, arremessadas pelo denunciado quando as trazia consigo.

Em revista pessoal, os guardas civis municipais encontraram R\$51,10 reais em dinheiro.

Oferecida a denúncia, determinou-se a notificação do acusado para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 124/125).

A denúncia foi recebida em 10 de novembro de 2022 (fls. 128/129).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais orais do Ministério Público e da Defensoria Pública (mídia).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar de atuação da Guarda Civil Municipal está entrosada com o mérito da ação penal e será analisada naquela oportunidade.

Não há outras preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 37/38), auto de exibição e apreensão (fls. 39), laudo pericial com resultado positivo para cocaína (fls. 143/145), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em solo policial, o acusado disse que a droga não era sua, mas sim de um conhecido. Não pode dizer o nome para não sofrer represálias. Alegou que conseguiu o dinheiro pedindo no semáforo. Afirmou que já foi preso diversas vezes pelo crime de furto em razão do seu vício em drogas (fls. 08).

Em Juízo, o réu disse que tem 30 anos. É autônomo e ajudante de pedreiro. Começou a fumar pedras de crack na noite anterior. Cata reciclagem na rua e limpa calçadas, o dinheiro é decorrente desses serviços. Conseguiu dinheiro pedindo no semáforo. Ganhou sessenta e um reais e foi fumar drogas. No local pegou duas pedras de crack. Cada pedra custa cinco reais. Estava fazendo uso. Quando dava o último trago, os guardas ingressaram. O traficante jogou os entorpecentes e caiu tudo no seu colo. Catou o pote na mão e jogou para trás do sofá. Tinha dinheiro em seu poder. Ficou apavorado com aquele pote cair na sua mão. Confirmou que dispensou o pote ao ver os guardas. Acreditou que o traficante iria se apresentar na hora. O nome dele é Cláudio. Falou aos guardas que os entorpecentes não eram dele e não quis dar o nome do traficante por temer represálias (mídia).

A versão do acusado na fase do contraditório não convence.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos seus interesses.

O guarda civil municipal Aparecido Rosa de Farias contou que estavam em apoio ao CEPROSOM, órgão municipal de assistência social. Havia moradores de rua e davam apoio na atividade de cadastramento. No barraco, viu o acusado. Ao presenciar os guardas, ele jogou algo para trás do sofá. Fez a abordagem. Ao verificar o que foi jogado encontraram várias pedras de crack. Em revista pessoal localizaram dinheiro. Indagado, ele negou ser dono daquelas drogas, mas viu ele dispensando os entorpecentes. Havia outras pessoas perto do acusado. Não o conhecia até então (mídia).

O guarda civil municipal Hélio Henrique de Souza disse que faziam apoio ao CEPROSOM. Foram com a equipe de assistência social que iria fazer cadastramento de moradores de rua. Viram o réu jogando um pote atrás de um sofá. Fizeram a abordagem. No pote dispensado encontraram 50 pedras de crack. Ele tinha cinquenta reais em seu poder. Indagado, o réu disse que guardava aqueles entorpecentes a uma terceira pessoa. Viu ele dispensando as drogas, o réu admitiu que estava com aquelas pedras, mas não confirmou ser dono. Não o conhecia até então (mídia).

Ressalto que o depoimento de guardas civis municipais neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos agentes públicos, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pelo teor da prova oral colhida, guardas civis municipais auxiliavam funcionários do CEPROSOM a fazerem cadastro de pessoas em situação de rua quando, ao avistarem o denunciado em atividade suspeita, jogando objeto atrás de um sofá, decidiram fazer a abordagem.

Ao chegarem no local, os guardas constataram que se tratava de um pote que continha no seu interior 50 pedras de crack. Ainda neste contexto, procederam com a abordagem do denunciado, que trazia consigo a quantia de R\$51,10.

O réu afirmou a um dos guardas civis municipais e em solo policial que estava guardando os entorpecentes para um conhecido, o qual não quis identificar para não sofrer represálias (fls. 08).

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico, haja vista a quantidade, natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína em forma de crack), a conduta do acusado quando da prisão, as circunstâncias da abordagem, os antecedentes específicos no tráfico (reincidente específico) e o depoimento incriminador dos agentes públicos, tudo a apontar o réu como pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

A ação dos guardas civis municipais foi válida. É cediço que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal estabelece que a Guarda Civil Municipal será destinada apenas à proteção de bens, instalações e serviços dos municípios, não tendo ela, portanto, a função de garantir a segurança, bem como investigar a prática de crimes. No entanto, referida limitação não significa que a Guarda Municipal não possa prender

em flagrante quem estiver cometendo um delito.

"(...) 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10). (...)". (TJSP; Apelação 0003302-14.2014.8.26.0627; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 31/10/2017; Data de Registro: 06/11/2017).

A situação trazida pela Defensoria Pública em audiência quanto à atuação da Guarda Civil Municipal não se assemelha àquela colocada em discussão por ocasião da decisão de uma das Turmas do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.977.119 (cf. STJ, REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

Decidiu-se naquele julgamento a respeito da limitação da atuação da Guarda Municipal em diligências investigativas, inerentes à atuação da polícia judiciária. No caso em tela, no entanto, na garantia da ordem pública, não se poderia exigir que os guardas civis municipais simplesmente acionassem a Polícia Civil ou Militar para que, apenas então, fosse efetuada a abordagem do acusado, que dispensou drogas atrás de um sofá com o intuito de ocultar o ilícito, e apenas depois se verificasse que o réu havia dispensado entorpecentes, correndo o risco de o denunciado obter sucesso em se desvencilhar da região do crime.

No caso, não há evidência de atuação ilegal da ação da Guarda Civil Municipal, com a observação de que os agentes públicos somente atuaram para a manutenção da ordem pública violada pela prática do crime de tráfico de drogas e davam apoio ao trabalho do CEPROSOM (órgão municipal) na atividade de cadastramento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A respeito da atuação da Guarda Civil Municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.281.774/SP, reafirmou a tese de que não há qualquer proibição à atuação dos guardas civis municipais, em conformidade com o voto do Ministro

Alexandre de Moraes:

"Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito. Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. (...).Entendo que essa interpretação do art. 144 é de cunho constitucional e tem relevância gigantesca, porque são inúmeras guardas civis em todos os municípios. Consequentemente, pelo cabimento do recurso os municípios." (STF, RE 1281774 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 18-08-2021 PUBLIC 19-08-2021).

Na mesma direção:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (STF, HC 212635 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022).

Aliás, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral do tema, no RE nº 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux, em que se discute o alcance do art. 144, § 8º, da CF, envolvendo a atuação de guardas municipais (cf. STF, RE 608588 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 06-06-2013 PUBLIC 07-06-2013).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos guardas civis municipais para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Por outro lado, não foram arroladas testemunhas de defesa que corroborassem a versão do acusado de não ter qualquer envolvimento com a traficância ilícita, devendo prevalecer o relato dos agentes públicos que presenciaram a ação delitiva e o prenderam em flagrante delito.

Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade, natureza das drogas apreendidas e das circunstâncias da prisão, com depoimento incriminador dos guardas civis municipais.

Em conformidade com os ensinamentos de Cleber Masson:

"Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica, necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias "mulas" (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São

Paulo: MÉTODO, 2019).

A respeito do assunto, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim já decidiu:

"Tráfico de entorpecentes – Dolo de traficar – Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...)" (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indubitáveis. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância (...)" (TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma, o que é o caso dos autos.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

Registre-se que eventual uso de álcool ou droga não exime a responsabilidade do réu, porque voluntária. Recorde-se da advertência feita por Fernando Capez, ao acentuar a seguinte lição:

"A embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de

livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 358).

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais dos artigos 59 do Código Penal e 42, da Lei nº 11.343/2006 são desfavoráveis ao réu, já que é portador de maus antecedentes (cf. Autos nº 0013068-22.2010.8.26.0566 – fls. 52/57), de modo que fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência específica (cf. Autos nº 1504786-03.2019.8.26.0566 – transitado em julgado aos 31/08/2020 - fls. 52/57). Dessa forma, elevo a pena em 1/6, totalizando 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE – Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Todavia, deixo de aplicar o redutor previsto no §4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, por ser portador de maus antecedentes e reincidente específico.

O valor do dia multa será fixado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, sobretudo pela natureza e quantidade das drogas em discussão (cocaína na forma de pedra de crack), nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força quantidade de pena imposta (superior a 04 anos), bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44 da Lei nº 11.343/2006.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JONATHAN DOS SANTOS GIMENES, qualificado nos autos, às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto voltar a praticar o comércio espúrio de drogas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido, anotando-se que é reincidente específico e portador de maus antecedentes.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Após o trânsito em julgado, o nome do acusado deverá ser lançado no rol dos culpados.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA